

1506966-31.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... local dos fatos em conhecido ponto de tráfico juntamente de seu colega. Realizaram breve campana de aproximadamente cinco minutos. Avistaram o réu e algumas pessoas iam até ele, e trocavam alguma coisa, em modus operandi típico de tráfico. Abordaram o réu. Em revista pessoal, localizou com o acusado 03 pedras de crack e 50 reais. O próprio réu indicou que havia outras drogas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506966-31.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506966-31.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079213/2022 - 01º D.P. SE, 23784573 - 01º D.P. SE, 2079213 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO PEDROSO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

ADRIANO PEDROSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de, no dia 22 de março de 2022, por volta das 11h30, na Rua Junqueira Freire, 54, Liberdade, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazer consigo e guardar, para fins de entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, 03 (três) invólucros contendo Tetrahydrocannabinol (THC), substância vulgarmente conhecida por "maconha", com massa líquida de 9,6g (nove gramas e seis decigramas) e 17 (dezessete) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de "crack", com massa líquida de 3,6g (três gramas e seis decigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 03/04, laudo de constatação provisório da presença dos princípios ativos a fls. 17/20 e fotografia de fls. 45, substâncias entorpecentes de uso proscrito na forma da Portaria ANVISA 344/98, sem autorização

e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante e sua prisão foi convertida em preventiva por decisão datada de 23 de março de 2022 em audiência de custódia (fls. 65/664). Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, tendo sido a denúncia recebida em 20 de abril de 2022 (fls. 106/111).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio de defensor público.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, alegou em sede preliminar quebra da cadeia de custódia. As pedras encontradas com o réu foram misturadas com as pedras encontradas na barraca em lacre único (Art. 158-A, CPP). Também preliminarmente pugnou pela violação de domicílio no ingresso à barraca, moradia do réu, morador de rua. No mérito, subsidiariamente, desclassificação para o artigo 28, Lei nº 11.343/06, pena base no mínimo legal, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analiso, inicialmente, as preliminares arguidas pela defesa.

Alega a defesa, em apertada síntese que houve quebra da cadeia de custódia no armazenamento das drogas apreendidas. Houve dois momentos de apreensão de drogas. O primeiro, decorrente de revista pessoal do réu, com quem foram localizadas 03 porções de crack. Logo em seguida, houve a apreensão das drogas encontradas dentro de uma barraca: 14 porções de crack e 03 porções de maconha.

De fato, todas as porções de crack foram apreendidas em um mesmo compartimento: lacre nº 0072413 (fls. 09).

Em que pese a alegação defensiva, verifica-se que não houve violação do artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

Cabe frisar que, no caso concreto, todas as drogas foram apreendidas no mesmo contexto fático de abordagem do réu em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Em revista pessoal localizaram algumas porções de crack. O próprio acusado informou que havia outras drogas dentro de uma barraca. Lá localizaram outras porções de crack e de maconha. As drogas apreendidas no local indicado pelo réu são de mesma espécie das drogas com ele encontradas, e foram apresentadas à autoridade policial, que formalizou a apreensão e providenciou o lacre para a realização da perícia.

Não verifico, portanto, quebra de cadeia de custódia que implique a nulidade da apreensão e da prova dela decorrente.

Quanto à alegada violação de domicílio, a defesa também pugna pela declaração da nulidade da apreensão, uma vez que os policiais ingressaram na barraca, local de moradia do réu, sem seu consentimento e sem mandado judicial, em violação ao artigo 5º, XI da Constituição Federal. Aduz a defesa que os policiais não documentaram tal ação nem por filmagem nem por meio de testemunha, fatos que dariam maior força a seus depoimentos em Juízo, consoante determinou o HC 598051/SP.

Em que pese o alegado pela defesa, o entendimento fixado no precedente do HC 598.051/SP fora anulado no tocante à necessidade de gravação audiovisual e registro escrito do morador, nos termos do decidido no RE 1.342.077/SP, Min. Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 02/12/2021.

O STJ, quando do julgamento do HC 598.051/SP sobrepujou suas funções, violando a separação de poderes (artigo 2º da Constituição Federal), e ao exigir a gravação do consentimento do morador, ou registro escrito de consentimento inovou na ordem jurídica, atuando como legislador.

Neste sentido:

(...) o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência – gravação audiovisual da anuência de entrada no local – para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral.

Em que pese a boa vontade e a sólida fundamentação em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.

(...)

Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009).

(...)

Assim atuando, o Superior Tribunal de Justiça tornou conflituosa a relação entre o juiz e o legislador e desrespeitou, no exercício da interpretação, uma importante expressão restritiva do poder dos juízes enunciada pelo JUSTICE HOLMES, em 1917: "os juízes fazem e devem fazer obra legislativa, mas se nos interstícios da lei: não movem massas, mas somente moléculas" (Southern Pacific Co. v. Jensen, diss. Op. 244 US 205, 221 – 1917). Incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE. Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação.

Ora, o comando constitucional que assegura a inviolabilidade do domicílio elenca exceções, entre elas, o flagrante delito, que excepciona a tal garantia tanto durante o dia quanto durante à noite.

Neste sentido foi o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.342.077: O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.

A situação flagrancial, como é a dos autos, dispensa o consentimento do morador

para que haja o ingresso na residência, uma vez que o diferimento da diligência, nas circunstâncias narradas na denúncia, acarretaria a própria perda da materialidade delitiva. Não seria razoável exigir dos policiais civis, após a apreensão de drogas na posse do réu e com indicação de plano por ele no sentido de que guardava outras porções em sua barraca, que conduzissem o réu, instaurassem o inquérito policial para que, no futuro, pudessem voltar ao local os fatos munidos de um mandado de busca e apreensão domiciliar. Conforme exposto, trata-se de situação de apreensão que decorre imediatamente da localização de drogas com o flagrante, em ponto de venda de drogas, com indicação por ele da barraca onde estariam depositadas as demais porções de entorpecentes, em evidente situação flagrante, o que justificou, legitimamente, as buscas nesse local.

Afasto, portanto, a segunda preliminar arguida e passo à análise do mérito.

No mérito, a pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 51/53), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 03/04), pela fotografia de fls. 45, e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 97/99), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria do crime é certa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 11).

Em Juízo, o réu negou a prática delitiva. Disse que na data dos fatos foi comprar drogas, pois é usuário e foi abordado no meio da rua. Os policiais perguntaram se tinha "passagem"; respondeu que sim. Havia comprado 03 pedras de crack e que os 50 reais eram da reciclagem. Estava com sua carroça que deixou na esquina para comprar entorpecentes.

Em sede policial, a testemunha policial civil Eliedes Lombardi, relatou que: "que nesta data, estava diligenciando pelo local dos fatos, junto com seu colega, ora condutor, conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, que efetuaram uma breve campanha e avistaram algumas pessoas se aproximando de ADRIANO, ora indiciado, e lhe entregando algo em suas mãos, em seguida o mesmo entregava algo para essas pessoas. Num determinado momento se aproximaram do indiciado para efetuar a abordagem, em revista pessoal foi achado 03 pedras de substância aparentemente entorpecente conhecida como Crack e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, e em uma barraca indicada por ele foram achados mais 14 pedras de substância aparentemente entorpecente conhecida como Crack, 03 porções de substância aparentemente entorpecente conhecida como Maconha e a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais) em espécie. Diante dos fatos procederam à apreensão das substâncias e do valor localizado, encaminhando o indiciado a esta Distrital.." (fls. 07/08).

Em Juízo, Eliedes Lombardi declarou que estava no local dos fatos em conhecido ponto de tráfico juntamente de seu colega. Realizaram breve campanha de aproximadamente cinco minutos. Avistaram o réu e algumas pessoas iam até ele, e trocavam alguma coisa, em modus operandi típico de tráfico. Abordaram o réu. Em revista pessoal, localizou com o acusado 03 pedras de crack e 50 reais. O próprio réu indicou que havia outras drogas numa barraca próxima do local. Lá, o colega do depoente encontrou mais 14 pedras de crack, três papéis de maconha e 60 reais em dinheiro. Esclareceu que lá é uma "mini-crackolândia". Não conhecia o réu. Indagado se o réu declarou condição de usuário, respondeu que sim, e que muito provavelmente o réu faria uso de entorpecente e estaria envolvido no tráfico para sustentar o vício

Na Delegacia, o também policial militar Fernando Scarpante Martins Fernando, narrou que: "nesta data, estava diligenciando pelo local dos fatos, junto com seu colega, ora testemunha, conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, que efetuaram uma breve campanha e avistaram algumas pessoas se aproximando de ADRIANO, ora indiciado, e lhe entregando algo em suas mãos, em seguida o mesmo entregava algo para essas pessoas. Num determinado momento se aproximaram do indiciado para efetuar a abordagem, em revista pessoal foi achado 03 pedras de substância aparentemente entorpecente conhecida como Crack e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, e em uma barraca indicada por ele foram achados mais 14 pedras de

substância aparentemente entorpecente conhecida como Crack, 03 porções de substância aparentemente entorpecente conhecida como Maconha e a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais) em espécie. Diante dos fatos procederam à apreensão das substâncias e do valor localizado, encaminhando o indiciado a esta Distrital" (fls. 05/06).

Em Juízo, Fernando Scarpante Martins, disse que no dia estava com seu parceiro em diligência em local conhecido pelo forte tráfico de drogas. Efetuaram breve campanha em viatura descaracterizada. Avistaram o réu; algumas pessoas se aproximavam dele, trocavam coisas e se evadiam do local. Seu parceiro procedeu a revista e com o réu localizou 3 pedras de crack e 50 reais. Posteriormente, o réu indicou uma barraca onde estavam outros entorpecentes. Lá o depoente encontrou 14 pedras de crack, 3 porções de maconha e 60 reais trocados em cima de uma poltrona. Assim procederam à prisão em flagrante do réu e o conduziram à Delegacia.

Essas foram as provas orais produzidas.

Extraí-se da prova oral colhida que na ocasião dos fatos os policiais militares realizavam patrulhamento, quando se deslocaram até local conhecido ponto de tráfico de drogas. Lá chegando avistaram o réu em provável traficância. Pessoas se dirigiam até ele faziam uma troca. Após breve campanha procederam a abordagem do acusado.

Em revista pessoal localizaram 03 pedras de crack e 50 reais em dinheiro. O próprio réu indicou que dentro de uma barraca havia outras drogas. Nessa barraca, em cima de uma poltrona localizaram 14 pedras de crack, 03 porções de maconha e 60 reais em notas trocadas.

Consigna-se, por oportuno, que inexiste motivo para que os depoimentos dos policiais militares sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e com a prova documental juntada nos autos.

Ressalte-se que as testemunhas foram expressamente (e por mais de uma vez) questionadas sobre as circunstâncias do crime, em especial se efetivamente visualizaram o réu comercializar as drogas, ao que foi respondido afirmativamente, com esclarecimento de que aguardaram, para a certeza exigida, a aproximação e compra de entorpecentes por, pelo menos, três usuários.

A versão do réu restou isolada no conjunto probatório e não foi infirmada pela prova colhida em Juízo.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância, que foi demonstrada pela quantidade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos, todos separados em porções individuais e prontos para a venda, além da confirmação, pelas testemunhas, de visualização de atos de efetiva comercialização. Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas, a despeito da narrativa do acusado, a materialidade e a autoria delitiva do crime descrito na denúncia, sendo de rigor sua condenação pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, a quantidade e a qualidade dos entorpecentes não autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A prática do crime em livramento condicional é circunstância a ser considerada na segunda fase de dosimetria, porque vinculada à condenação anterior, geradora de reincidência, não comportando dupla valoração, sob pena de bis in idem. Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, depreende-se dos autos que o réu é duplamente reincidente (i- Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal. Proc. nº 0005827-71.2016.8.26.0635; PEC nº 0015374-74.2016.8.26.0041. Trânsito em julgado para a defesa em 01/08/2018 - fls. 54/55; ii- Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal. Proc. nº 1519449-98.2019.8.26.0228; PEC nº 0024987-16.2019.8.26.0041. Trânsito em julgado para a defesa em 23/09/2020 - fls. 55/56 - específico em tráfico). Ausentes circunstâncias atenuantes e resalto que a confissão da mera posse de droga para uso não enseja a aplicação da atenuante, nos termos da Súmula 630, STJ. Em razão da dupla reincidência, agravo a pena em 1/5, alcançando 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena,

valendo consignar-se que o acusado é reincidente específico em tráfico de drogas, conforme atestado nos autos, o que torna inaplicável o redutor do parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06.

Pena em definitivo em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto, ante a reincidência específica do réu por tráfico de drogas e roubo (fls. 54/58).

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente. Ademais, verifico que o réu se encontrava em livramento condicional, devendo a avaliação do lapso para progressão ser analisado no Juízo das Execuções.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu ADRIANO PEDROSO às penas de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva do acusado, eis que imprescindível à garantia da ordem pública, ressaltando-se a reincidência específica e a prática do crime em gozo de livramento condicional.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas.

Em caso de recurso, expeça-se a Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC competente por mensagem eletrônica.

Oficie-se à VEC à execução anterior.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA